

1501827-86.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... Vitor Teixeira de Freitas - j. 28/02/2021 - grifei)

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA E VIOLÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. "RES" NA POSSE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS SUFICIENTES A CONVENCER DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-

3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501827-86.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2322832/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 21637016 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

3370/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2322832 - 02º D.P. PIRACICABA,

3370/21/922 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACKSON APARECIDO ROQUE e outro

Vítima:

COOP COOPERATIVA DE CONSUMO

Artigo da Denúncia:

*

Aos 28 dias do mês de junho de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel. Apresentados o representante da vítima, Lucca Silva Miranda, e as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Wagner Munhoz Bacco e Paulo Sérgio Torin.

Ausentes os acusados Jackson Aparecido Roque, o qual foi devidamente intimado, conforme certidão de fls.203; e Cristiano Gomes dos Santos, o qual não foi localizado pelo Oficial de Justiça, conforme certidão de fls.217.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) vítima(s) (Lucca) pelo sistema virtual.

Pelas partes foi dito que desistem da oitiva das testemunhas Wagner Munhoz Bacco e Paulo Sérgio Torin.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Tendo em vista que o corréu Jackson Aparecido Roque foi devidamente intimado e não compareceu à audiência e, que o corréu Cristiano Gomes dos Santos mudou de endereço e não comunicou o juízo, DECRETO AS SUAS REVELIAS.

Homologo a desistência das partes em relação às testemunhas Wagner Munhoz Bacco e Paulo Sérgio Torin.

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, JACKSON APARECIDO ROQUE e CRISTIANO GOMES DOS SANTOS estão sendo processados como incursos no artigo 155, § 1º e 4º, incisos I, II e IV, c.c o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Feito regularmente processado.

ADITO A INICIAL PARA CONSTAR OS RÉUS COMO INCURSOS no artigo 155, § 1º e 4º, incisos I, II e IV, c.c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, TENDO EM VISTA QUE no dia 27 de novembro de 2021, por volta de 01h45min, na Avenida Professor Alberto Volet Sachs, n. 2030, Jardim Elite, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, JACKSON APARECIDO ROQUE, qualificado e indiciado às fls. 07, e CRISTIANO GOMES DOS SANTOS, qualificado e indiciado às fls. 08, agindo em concurso e com identidade de desígnios delituosos, durante o período de repouso noturno, tentaram subtrair, para si ou para outrem, mediante escalada e rompimento de obstáculo, cerca de 10 (dez) quilos de fios e cabos elétricos em cobre, pertencentes ao Supermercado Coop, representado por Lucca Silva Miranda, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A ausência de CRISTIANO na presente audiência impede o acordo de não persecução penal e a suspensão condicional do processo.

Procede a ação penal.

DOS FATOS

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de novembro de 2021, por volta de 01h45min, na Avenida Professor Alberto Volet Sachs, n. 2030, Jardim Elite, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, JACKSON APARECIDO ROQUE, qualificado e indiciado às fls. 07, e CRISTIANO GOMES DOS SANTOS, qualificado e indiciado às fls. 08, agindo em concurso e com identidade de desígnios delituosos, durante o período de repouso noturno, tentaram subtrair, para si ou para outrem, mediante escalada e rompimento de obstáculo, cerca de 10 (dez) quilos de fios e cabos elétricos em cobre, pertencentes ao Supermercado Coop, representado por Lucca Silva Miranda, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo consta, os denunciados, aproveitando-se da vigilância atenuada em razão do período de repouso noturno, acessaram Supermercado Coop pulando o alambrado que circunda o local e, com o uso de um alicate, danificaram os tubos que guarneciam os fios e cabos de cobre e os cortaram para a subtração. Contudo, antes que deixassem o local em poder dos fios, foram surpreendidos por guardas municipais. Ao lado dos denunciados, estavam apreenderam o material elétrico, já separado para a subtração, e um alicate. Na delegacia, os denunciados ficaram silentes.

O crime não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos denunciados, quais sejam, a pronta intervenção dos guardas municipais.

DA PROVA NA FASE JUDICIAL

Lucca Silva Miranda - Representante da vítima - confirmou a ocorrência do furto na empresa-vítima e que duas pessoas foram detidas em poder de alicate, cabo de aço. Eles pularam por cima da cerca. Eles ingressaram pulando a cerca de dois metros de altura. Os portões do local estavam fechados. São fechados sempre por volta de 22 horas. Tem imagens do ingresso dos réus pulando a cerca. Eram duas pessoas.

Wagner Munhoz Bacco - GCM - e Paulo Roberto Torin - GCM - confirmaram as prisões dos réus no local dos fatos quando ouvidos na fase policial.

Não há dúvidas quanto à autoria e tentativa de subtração.

Os réus não compareceram para ser interrogados.

DA PENA

JACKSON APARECIDO ROQUE é reincidente (fls.45/47).

CRISTIANO GOMES DOS SANTOS é primário (fls.48/49).

Regime semiaberto para JACKSON.

Regime aberto para CRISTIANO. Possível a substituição por restritiva de direitos.

DO PEDIDO FINAL

Pela procedência da ação nos termos da inicial e seu aditamento.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, Jackson Aparecido Roque e Cristiano Gomes dos Santos foram denunciados como incursos no artigo 155, § 1º e 4º, incisos I, II e IV, c. c/ o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Segundo a denúncia (fls. 124-125), no dia 27 de novembro de 2021, por volta de 01h45, na avenida Professor Alberto Volet Sachs, n. 2030, Jardim Elite, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Jackson e Cristiano, agindo em concurso e com identidade de desígnios delituosos, durante o período de repouso noturno, tentaram subtrair, para si ou para outrem, mediante escalada, cerca de 10 (dez) quilos de fios e cabos elétricos em cobre, pertencentes ao Supermercado Coop, representado por Lucca Silva Miranda, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ainda de acordo com a inicial, os réus aproveitando-se da vigilância atenuada em razão do período de repouso noturno, pularam uma grade que circunda o Supermercado Coop e, com o uso de um alicate, cortaram e separaram fios e cabos de cobre da empresa para a subtração. Contudo, antes que deixassem o local em poder dos fios, foram surpreendidos por guardas municipais. Ao lado dos réus, estavam apreenderam o material elétrico, já separado para a subtração, e um alicate. O crime não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos réus, quais sejam, a pronta intervenção dos guardas municipais.

Interrogados na Delegacia de Polícia, os réus exerceram o direito constitucional ao silêncio (fls. 7 e 8).

Em solo policial, Lucca Silva Miranda, representante da vítima, contou que: "estava em sua residência quando foi informado de que câmeras de monitoramento do Supermercado Coop, onde trabalha, teriam captado dois homens furtando fios elétricos do estabelecimento, em cujo interior teriam ingressado após pularem a grade que cerca o imóvel. De imediato, se dirigiu ao local, após acionar a GCM. Já nesta delegacia, reconheceu os fios localizados em poder dos suspeitos, dada a sua especificidade, como sendo pertencentes ao estabelecimento. Neste ato, se compromete a apresentar mídia digital contendo as filmagens à autoridade policial responsável pela investigação" (fls. 6).

Paulo Roberto Torin, guarda municipal, narrou que: "estava com seu parceiro em patrulhamento de rotina, quando foram acionados para averiguação de possível furto em curso no interior do supermercado existente no local dos fatos. Segundo informado, após pularem a grade que delimita o imóvel, dois suspeitos teriam ingressado no estabelecimento e estariam realizando a subtração de fios elétricos, conforme flagrado por câmeras de monitoramento. Ao chegarem no sítio dos acontecimentos, se depararam com dois homens no exato momento em que eles pulavam a mesma grade, desta feita de dentro para fora. Realizada a abordagem, com os averiguados, identificados como Jackson Aparecido Roque e Cristiano Gomes dos Santos, nada de ilícito foi localizado. Próximo de onde ambos estavam, foram localizados diversos cabos de energia e, ainda, um alicate para corte, tudo separado para ser carregado. Diante da aparente prática delitiva, os guardas apresentaram os suspeitos nesta Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as medidas cabíveis, sendo necessário o emprego de algemas" (fls. 4).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo guarda municipal Wagner Munhoz Bacco (fls. 5).

Às fls. 17, auto de exibição e apreensão. Às fls. 18, auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega (os fios foram avaliados em R\$350,00). Às fls. 225-229, laudo do local.

Às fls. 45-47, certidão de objeto e pé que indica a reincidência do requerido

Jackson (autos n.º 0018793-07.2014.8.26.0451 - furto - trânsito em julgado para a Defesa em 6/2/2017, pena julgada extinta em 28/1/2021).

Às fls. 48-49, certidão de objeto e pé que indica a primariedade do requerido Cristiano.

Juntado o laudo de fls. 225-229, a acusação aditou a denúncia para constar também a qualificadora do art. 155, §14º, I, CP.

- DA INSTRUÇÃO EM AUDIÊNCIA

Durante a instrução, foram colhidos os seguintes elementos probatórios:

a) Inicialmente, foi ouvido Lucca Silva Miranda, representante da vítima. Relatou que identificaram um rompimento de cerca e fecharam dias antes. A fiscal da loja ligou para ele e disse que tinha ocorrido uma invasão na loja. Foi até lá e a guarda tinha rendido e abordados dois rapazes. Eles estavam sentados e os objetos estavam no chão: alicate e o para-raios enrolado. Não entraram pela cerca rompida, mas sim pularam por cima da cerca. O supermercado é todo cercado. Nesse horário, já estava fechado. [Como o senhor sabe que as pessoas entraram pulando a cerca?] Disse ter imagens dos dois rapazes pulando a cerca. As pessoas foram abordadas quando pulavam a grade de dentro para fora. Os fios e para-raios são do mercado. Viu marcação de pés no telhado onde ficavam.

Os réus são revéis.

- DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA

Tendo em vista o valor dos bens (R\$350,00) e que eles foram restituídos ao supermercado, o caso é de absolvição por atipicidade material da conduta, em virtude do reconhecimento do princípio da insignificância.

Nesse contexto, de início, saliente-se que insignificância é uma causa de exclusão da tipicidade, como afirma, a propósito, Paulo Queiroz:

"O princípio da insignificância constitui, portanto, um instrumento por cujo meio o juiz, em razão da manifesta desproporção entre crime e castigo, reconhece o caráter não criminoso de um fato que, embora formalmente típico, não constitui uma lesão digna de proteção penal, por não traduzir uma violação realmente importante ao bem jurídico tutelado" (Direito penal: parte geral, v. 1. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 91).

Dinamizando a incidência da insignificância, o Supremo Tribunal Federal, fixou o entendimento sobre a necessidade da verificação de quatro pressupostos para sua aplicação: a) a pequena ofensividade da conduta do agente; b) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; c) nenhuma periculosidade social da ação; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada:

"E M E N T A: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGÍTIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - "RES FURTIVA" NO VALOR DE R\$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. - O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais,

notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.” (HC 84412, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. em 19/10/2004).

Este julgado tornou-se o verdadeiro leading case da matéria e vem sendo reiterado por inúmeras decisões, tanto do próprio Supremo Tribunal Federal, quanto deste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, a título exemplificativo, citam-se os seguintes precedentes: a) no STF: HC 97129/RS, Min. Rel. Eros Grau; HC 97189/RS, Min. Rel. Ellen Gracie; STF, HC 96496/MT, Min. Rel. Eros Grau; HC 105974, Min. Rel. Ayres Britto; HC 93393, Min. Rel. César Peluso; HC 93453, Min. Rel. Joaquim Barbosa; b) no STJ, RHC 23.376/MG, Min. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho; HC 198996/SC, Min. Rel. OG Fernandes; HC 34626/MG, Min. Rel. Félix Fischer; STJ, HC 18314/RJ; HC 139015/SP, Min. Rel. OG Fernandes; HC 122435/MG, Min. Rel. Celso Limongi.

Ora, a aplicação do princípio da insignificância é uma questão de política criminal, afastando a intervenção penal para delitos que, do ponto de vista jurídico-penal, são considerados menos reprováveis. E, ao fazê-lo, permite-se que o poder punitivo seja exercido de forma mais enérgica em relação aos delitos que, efetivamente, atentam contra a paz social.

Saliente-se, ainda, que o reconhecimento da insignificância não irá causar qualquer desamparo à vítima. Pelo contrário, o que se postula é que seja reconhecida a insignificância do ponto de vista jurídico-penal. Ou seja, o que se requer é o afastamento das consequências jurídico-penais. Com isso, a vítima, caso entenda que tenha sofrido algum tipo de prejuízo, ainda poderá pleitear a devida reparação na esfera civil, eis que a sentença que reconhece a atipicidade da conduta não produz coisa julgada na esfera extrapenal (CPP, art. 67, III). Percebe-se, dessa forma, que somente se justificaria manter a persecução penal para assegurar à vítima um título executivo judicial, eis que a sentença penal condenatória torna certa a obrigação de indenizar (CP, art. 91 c. c/ CPC, art. 515, VI). Todavia, é necessário separar as esferas penal e civil e, assim, retiradas as consequências jurídico-penais da conduta, não se justifica a manutenção do processo penal, seja por causa dos inúmeros gravames que serão causados ao imputado, seja pelo fato que os interesses da vítima - meramente econômicos - ainda estarão amparados pelo ordenamento.

Se é assim, impõe-se a absolvição, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

- DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Como as provas produzidas no presente feito não foram aptas a demonstrar, de forma cabal, a caracterização do crime imputado, tem-se que a prolação de um decreto absolutório é a única medida adequada ao caso, para que se respeite o princípio basilar do in dubio pro reo, tudo nos termos do artigo 386, inciso VII, Código de Processo Penal.

- DA FIXAÇÃO DA PENA

Subsidiariamente, na remota possibilidade de condenação, passa-se a discorrer sobre a pena.

a) Do afastamento da qualificadora do art. 155, § 4º, II, CP

A prática do furto qualificado pela escalada pressupõe a superação de algo utilizado para a proteção da coisa. Nesse sentido, leciona Rogério Greco, ao apontar que, “[...] em sede doutrinária, considera-se obstáculo tudo aquilo que tenha a finalidade precípua de proteger a coisa e que também não seja a ela inerente” (GRECO, Rogério. Código Penal: comentado. 5. ed. Niterói: Impetus, 2011, p. 417).

Não é diferente o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É imprescindível, para a constatação da qualificadora referente à escalada no crime de furto, a realização do exame de corpo de delito, o qual pode ser suprido pela prova testemunhal ou outro meio indireto somente quando os vestígios tenham

desaparecido por completo ou o lugar se tenha tornado impróprio para a constatação dos peritos, o que não foi evidenciado nos autos (HC 456.927/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019).

Trata-se, pois, de figura qualificada que deixa vestígios e, por isso é imprescindível a realização de um laudo que comprove a escalada (CPP, art. 158). Entretanto, o laudo de exame do local dos fatos não comprova a escalada. Apenas há a informação de que um cano estava avariado, não havendo como inferir em que tal cano se relacionaria com a escalada.

Portanto, não restou demonstrada a qualificadora prevista pelo art. 155, § 4º, II, do Código Penal.

b) Do afastamento da qualificadora do art. 155, § 4º, IV, CP

No que diz respeito ao concurso de agentes, de rigor o seu afastamento, posto que não demonstrado nos autos o liame subjetivo entre os réus.

c) Da pena-base

De rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal, pois não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

d) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, a reincidência de Jackson permite o aumento da pena em 1/6.

e) Do afastamento do repouso noturno

Na terceira etapa de dosimetria de pena, é de rigor o afastamento da majorante prevista no art. 155, § 1º do CP, pois é imprescindível a perturbação do repouso noturno, o que não se pode considerar ter ocorrido, tendo em vista que a suposta subtração se deu em estabelecimento que se encontrava fechado, sem a presença de pessoas no seu interior.

É o que entende a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Não obstante, deve ser afastada a causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal (crime praticado durante o repouso noturno), pois para que seja configurada esta causa, não basta que o furto ocorra no período noturno, mas que a vítima se encontre em repouso no local furtado, o que não ocorreu no caso presente, pois o veículo estava estacionado na via pública. Nesse sentido:

'Predomina em nossos pretórios o entendimento de que a agravante especial de furto noturno só pode ser reconhecida quando a ação ocorre em casa habitada, cujos moradores estejam repousando. Incabível tal reconhecimento por ter sido cometido contra estabelecimento comercial' (TACRIM-SP AC Rel. MafraCarbonieri RJD 6/97);

'Impõe-se, no entanto, a exclusão da majorante do furto noturno, pois demonstrado nos autos que a ação ocorreu na via pública, não se podendo cogitar, portanto, de 'repouso noturno', como exige o dispositivo. Nesse sentido, já se decidiu que, 'para que se caracterize a qualificadora do repouso noturno, é necessário que o furto seja perpetrado em casa habitada, cujos moradores estejam dormindo' (RJD 25/191, rel. Junqueira Sangirardi), bem como que 'para o reconhecimento da agravante do art. 155, § 1º, do CP, é necessário que o furto seja praticado em casa habitada, onde haja alguém repousando. Deste modo, o furto de veículo em via pública não enseja a aplicação da majorante do furto noturno' (RT596/410)' (Apelação Criminal nº 0079341-95.2018.8.26.0050, Rel. Des. Vico Mañas, j. em 03.04.2019)". (Apelação criminal 1500872-89.2020.8.26.0599, Rel. Des. Heitor Donizete de Oliveira, j. em 08.02.2022)

Além disso, deve ser levada em consideração a posição topográfica da causa de aumento do repouso noturno, redigida logo após o caput e bem antes da definição das qualificadoras do furto, inferindo-se, por isso, que ela somente é aplicável ao furto simples, não podendo ser utilizada para majorar a pena do furto qualificado, no qual as penas previstas já são superiores.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas.

Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão da res furtiva em poder do apelante. Crime praticado mediante rompimento de obstáculo.

Repouso noturno em furto qualificado. Não incidência. Jurisprudência consolidada.

Condenação mantida.

PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos. Personalidade voltada à prática

de delitos não evidenciada (ausência de estudo psicossocial específico). Maus antecedentes. Elevação em 1/6. Proporcionalidade. Reincidência específica. Acréscimo na fração de 1/5. Razoabilidade. Regime inicial fechado. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, II e III). Afastamento da indenização pela reparação dos danos. Falta de instauração de incidente processual próprio, observado o devido processo legal e a ampla defesa. Apelo provido em parte para excluir a causa de aumento do repouso noturno e reduzir as penas; e afastar a reparação de danos (TJ-SP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 1500169-55.2019.8.26.0580, Rel. Gilberto Ferreira da Cruz, julgado em 6/7/2020, grifos nossos)".

Assim também se manifesta a doutrina:

"É furto agravado ou qualificado o praticado durante o repouso noturno, aumentando-se a pena de um terço (art. 155, § 1º).

[...].

A agravação da pena em um terço é procedida sobre a reprimenda do furto simples e, por isso, não se refere às hipóteses de furto qualificado" (MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de direito penal: parte especial, arts. 121 a 234 do CP. 26. ed. rev. e atual. até 11 de março de 2009. São Paulo: Atlas, 2009, p. 196, grifos nossos, p. 193).

Sendo assim, mostra-se de rigor o afastamento da majorante do repouso noturno, eis que não ocorreu a "perturbação do repouso noturno".

e) Da tentativa

Na terceira etapa de dosimetria de pena, conforme se infere dos elementos de prova produzidos em juízo, os acusados não consumaram o delito, uma vez que foram presos pelos guardas municipais.

E, como sabido, a pena, no caso da tentativa, deve ser diminuída de acordo com o iter criminis percorrido:

"O quanto a ser reduzido será fixado proporcionalmente, segundo a gravidade e a lesividade concretas da ação tentada. Ou seja, quanto mais próxima a consumação, menor será a diminuição; logo, maior será a pena; quanto mais distante a consumação, maior a diminuição; portanto, menor a pena" (QUEIROZ, Paulo. Direito penal: parte geral. 13 ed. Salvador: Juspodivm, 2018, v. 1, p. 316).

Nessa linha também ensina Luiz Regis Prado:

"De modo geral, há de ser feita a redução entre 1/3 e 2/3, estatuída na lei, sendo o quantum baseado no desenvolvimento do iter criminis; vale dizer, quanto mais próximo da consumação, menor a redução, ou quanto mais distante da consumação, maior a redução pela tentativa" (Comentários ao Código Penal. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 109).

Assim, a minorante do art. 14, II, do Código Penal deve ser aplicada em seu patamar máximo.

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, conforme disposto nas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, assim como a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, no art. 33, § 3º, do Código Penal, não se pode apelar à gravidade em abstrato do delito para justificar a imposição de regime mais gravoso para o caso. Pugna-se, assim, pela fixação do regime inicial aberto.

- DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA (FURTO PRIVILEGIADO) – réu Cristiano

Sendo o requerido primário e havido apenas tentativa de furto, requer-se, nos termos do art. 155, §2º, do CP, a substituição da pena de reclusão pela de multa. Subsidiariamente, requer-se a substituição da reclusão pela detenção com a diminuição máximo de 2/3.

Ressalta-se que, mesmo sendo reconhecida a qualificadora do furto, a jurisprudência assentada é a de que "é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva" (Súmula 511, STJ)

- DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – réu Cristiano

No mais, aplicável ao caso, o disposto no artigo 44 do Código Penal: o crime não

foi cometido mediante violência ou grave ameaça, a pena aplicável ao caso não supera 4 anos e o réu Cristiano é primário.

- DO RECURSO EM LIBERDADE

Por fim, considerando que os requeridos responderam ao presente processo em liberdade, não praticaram crime com violência ou grave ameaça e não representam perigo à segurança da sociedade, requer-se que lhes seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

JACKSON APARECIDO ROQUE e CRISTIANO GOMES DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos II e IV, combinado com artigo 14, inciso II, do Código Penal, porque no dia 27 de novembro de 2021, por volta de 01h45, na Avenida Professor Alberto Volet Sachs, nº 2.030, Jardim Elite, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, agindo em concurso e com identidade de desígnios delituosos, durante o período de repouso noturno, tentaram subtrair, para si ou para outrem, mediante escalada, cerca de 10 (dez) quilos de fios e cabos elétricos em cobre, pertencentes ao Supermercado Coop, representado por L.S.M., não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo a denúncia, os réus, aproveitando-se da vigilância atenuada em razão do período de repouso noturno, pularam uma grade que circunda o Supermercado Coop e, com o uso de um alicate, cortaram e separaram fios e cabos de cobre da empresa para a subtração.

Contudo, antes que deixassem o local em poder dos fios, foram surpreendidos por guardas municipais.

Ao lado dos réus, apreenderam o material elétrico, já separado para a subtração, e um alicate.

Na delegacia, os réus ficaram silentes.

O crime não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos réus, quais sejam, a pronta intervenção dos guardas municipais.

A denúncia foi recebida (fls. 127/128), os réus citados (fls. 157 e 163), apresentando respostas escrita, na qual alegaram não haver questões preliminares, sendo as questões de mérito tratadas posteriormente (fls. 167/168).

O recebimento da denúncia foi mantido, designando-se audiência (fls. 169/172).

Durante a instrução, foi ouvido o representante da vítima, sendo decretada a revelia dos réus.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, recebo o aditamento da denúncia.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitiva do furto está consubstanciada no auto de exibição, apreensão e avaliação e entrega de fls. 18, segundo o qual a res foi avaliada em R\$ 350,00.

2) Da autoria

A autoria criminosa é certa e deve ser atribuída aos réus.

Na fase inquisitiva, os réus permaneceram calados (fls. 07/08) e, em Juízo, não compareceram para oferecerem suas versões sobre os fatos.

A autoria foi confirmada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos, sob o crivo do contraditório. Vejamos.

O representante da vítima L.S.M. declarou que tinha chegado em casa e o fiscal noturno ligou e avisou que tinha ocorrido uma invasão. Antes desse dia, tinham observado um corte na cerca e haviam fechado. Dias depois, no dia dos fatos, a fiscal ligou para ele e acionou a Polícia Militar. Quando chegou ao supermercado, os policiais já tinham detido os réus. Os objetos subtraídos, fios e para raio, estavam no chão, perto dos réus. Eles entraram pulando a cerca. O supermercado é todo cercado. O mercado fecha às 22h00. Na data dos fatos, só estava a funcionária da noite, porque todos os outros funcionários e clientes tinham ido embora. A grade

estava toda fechada e é vedada por solda. Pelas imagens da câmera de segurança, viram que os dois rapazes ingressaram no mercado pulando a cerca. Eles foram abordados pulando a grade de dentro para fora, com os objetos subtraídos. Os fios e para-raios tinham sido retirados do supermercado. Conhecia os réus, que passam no estacionamento pedindo dinheiro e catando latinhas para reciclagem.

Ouvido apenas na fase inquisitiva, o guarda municipal Paulo Sérgio Torin relatou que, na data e horário dos acontecimentos, estava com seu parceiro em patrulhamento de rotina, quando foram acionados para averiguação de possível furto em curso no interior do supermercado existente no local dos fatos. Segundo informado, após pularem a grade que delimita o imóvel, dois suspeitos teriam ingressado no estabelecimento e estariam realizando a subtração de fios elétricos, conforme flagrado por câmeras de monitoramento. Ao chegarem ao sítio dos acontecimentos, se depararam com dois homens no exato momento em que eles pulavam a mesma grade, desta feita de dentro para fora. Realizada a abordagem, com os averiguados, identificados como Jackson Aparecido Roque e Cristiano Gomes Dos Santos, nada de ilícito foi localizado. Próximo de onde ambos estavam foram localizados diversos cabos de energia e, ainda, um alicate para corte, tudo separado para ser carregado. Diante da aparente prática delitiva, os guardas apresentaram os réus na Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as medidas cabíveis, sendo necessário o emprego de algemas (fls. 04).

Na Delegacia de Polícia, o guarda municipal Wagner Munhoz Bacco contou que, na data e horário dos acontecimentos, estava com seu parceiro em patrulhamento de rotina quando foram informados de que câmeras de monitoramento do supermercado COOP teriam flagrado dois homens pulando a grade que delimita o estabelecimento, supostamente com vistas ao furto de fios elétricos. Ao chegarem ao sítio dos acontecimentos, se depararam com dois homens no exato momento em que eles tentavam se evadir. Tais homens foram surpreendidos enquanto pulavam aquela mesma grade, desta vez de dentro para fora. Realizada a abordagem, com os averiguados, identificados como Jackson Aparecido Roque e Cristiano Gomes Dos Santos, nada de ilícito foi localizado. Próximo de onde ambos estavam, porém, foram localizados diversos cabos de energia e, ainda, um alicate para corte, tudo separado para ser carregado. Diante da aparente prática delitiva, os guardas apresentaram os réus na Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as medidas cabíveis, sendo necessário o emprego de algemas (fls. 05).

Com efeito, a prova é suficiente para a certeza da acusação.

Os réus, em solo policial, nada mencionaram e, em Juízo, não compareceram para dar suas versões sobre os fatos.

O representante da vítima não presenciou a subtração, mas foi avisado, em sua residência, que as câmeras de segurança do supermercado captaram a presença de dois indivíduos furtando fios elétricos, os quais ingressado no local pulando a grade que cerca o imóvel. Quando chegou ao local, os réus já estavam detidos e o material subtraído ao lado deles, fora da mochila. Confirmou que viu pelas câmeras de segurança, que os réus ingressaram pulando as grades, que estavam fechadas, porque o supermercado já tinha encerrado as atividades diárias.

Os guardas civis, em solo policial, contaram que foram acionados em razão de possível furto em andamento no supermercado e, quando chegaram ao local, se depararam com os réus pulando a grade que cerca o estabelecimento, de dentro para fora. Eles foram abordados e nada de ilícito foi encontrado em poder deles, no entanto, nas proximidades, localizaram a fiação que já havia sido retirada e um alicate.

Nesse aspecto, após o acionamento, os guardas encontraram os réus pulando as grades do supermercado, de dentro para fora, bem como a res nas proximidades, o que indica que eles tinham envolvimento com os objetos que havia sido retirados do mercado. Terem sido os réus encontrados na posse dessa fiação, por si só, já faz presumir-se a autoria, cabendo aos próprios acusados a tarefa de afastar tal presunção.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples – Recurso defensivo – Absolvição – Fragilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Apreensão da res em poder do acusado gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova – Pena reclusiva

mantida - Dia-multa fixado no valor unitário mínimo legal - Regime inalterado dada a comprovada presença de antecedentes criminais - Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Ausência de recurso ministerial nesse sentido - Recurso parcialmente provido". (TJSP - Apelação Criminal 0000318-78.2015.8.26.0544. Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Fernando Torres Garcia - j. 20/08/2020 - grifei)

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pelo concurso de agentes - Sentença condenatória - Pleito absolutório inadmissível - Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva - Réu que foi surpreendido na posse do produto furtado, sem explicação plausível - Prova oral suficiente para a condenação - (...)". (TJSP - Apelação Criminal 1500587-42.2018.8.26.0575. Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto - j. 02/03/2021 - grifei)

"APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO - ARTIGO 155, § 1º e § 4º, inciso I, DO CÓDIGO PENAL - Subtração de diversos itens de vestuário do interior de estabelecimento comercial, mediante quebra da vidraça da loja, durante repouso noturno - Recurso defensivo que não questiona a autoria delitiva. Confissão. Apreensão em flagrância em posse da res. Ainda, palavras da vítima e dos servidores policiais seguras e consistentes. Condenação mantida - (...). RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP - Apelação Criminal 1501430-28.2019.8.26.0201. Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas - j. 28/02/2021 - grifei)

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA E VIOLÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. "RES" NA POSSE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS SUFICIENTES A CONVENCER DO DECRETO CONDENATÓRIO. CONSUMAÇÃO. A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA COISA SUBTRAÍDA É O BASTANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 59, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMPROVADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO RÉU. (...) 4. Encontro de parte da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor, tanto mais ante o reconhecimento que a vítima realizou do indigitado agente. Inversão do ônus da prova. Precedentes do STF, "mutatis mutandis" (ARE 822.045/SC - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 28.08.2014 - DJE 02.09.2014 e RE 731.662/SC - Rel. Min. Dias Toffoli - j. 22.05.2014 - DJE - 28.05.2014) e do STJ (ARE 329.535/PI - Rel. Min. Marilza Maynard - 6ªT. - DJE 25.08.2014 e HC 243.033/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - 5ªT. - j. 19.11.13) e do TJSP (Ap. 0086071-98.2013.8.26.0050 - Rel. Des. Salles Abreu - j. 17.09.2014; Ap. 0010663-73.2011.8.6.0664 - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - j. 02.09.2014 e Ap. 0090615-03.2011.8.26.0050 - Rel. Des. Grassi Neto - j. 20.03.2014). (...) (TJSP; Apelação Criminal 0038485-65.2013.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 07/12/2018).

APELAÇÃO DAS DEFESAS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E PELO CONCURSO DE AGENTES. VALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. "RES" ENCONTRADA EM PODER DOS RECORRENTES, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉUS CONFESSOS. TESTEMUNHOS DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. PRECEDENTES. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. "MUTATIO LIBELLI". FURTO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REGIME ABERTO MANTIDO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. (...) 2. Materialidade e autorias comprovadas com relação ao crime de furto. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado às espécies, sobretudo pelas provas orais, colhidas perante o contraditório, recepcionadas pelas demais provas dos autos. 3. Furto. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor. Precedentes do TJSP (Ap. 0000880-56.2011.8.26.0244 - 8ª C - Rel. Des. Alcides Malossi Junior - j. 23.02.2017 - DJe 23.02.2017; Ap. 0023445-74.2015.8.26.0405 - 3ª C - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - j. 14.02.2017 -

DJe 14.02.2017; Ap. 0002534-30.2011.8.26.0357 - 8ª C - Rel. Des. Carlos Monnerat - j. 09.02.2017 - DJe 16.02.2017; Ap. 0002710-04.2014.8.26.0066 - 9ª C - Rel. Des. Souza Nery - j. 15.12.2016 - DJe 09.01.2017 e Ap. 3001436-92.2013.8.26.0484 - 8ª C - Rel. Des. Grassi Neto - j. 22.09.2016 - DJe 31.01.2017). (...) (TJSP; Apelação 0042098-25.2015.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/04/2018; Data de Registro: 13/04/2018).

No caso dos autos, os réus, em solo policial, ficaram silentes e, em Juízo, não compareceram à audiência, de forma que a presunção se tornou certa.

A autoria, portanto, restou incontroversa.

3) Da escalada e do arrombamento

Neste momento, cabe perquirir sobre as qualificadoras da escalada e do arrombamento.

O laudo pericial de fls. 225/229 constatou que o acesso à área externa do supermercado se dava por portões, que quando da perícia estavam abertos. Também esclareceu que o perímetro era guardado por gradil metálico de aproximadamente 2 metros de altura.

Nesse sentido, considerando que os fatos ocorreram de madrugada, quando o supermercado estava sem funcionamento e os portões fechados, infere-se que os réus ingressaram na área externa por meio de escalada desse gradil, caracterizando a escalada.

Além disso, o mesmo laudo pericial confirmou que havia danos nos condutores de fios, situados na parte externa da parede do estabelecimento, confirmando o arrombamento.

3) Do concurso de pessoas

No caso dos autos, os guardas avistaram ambos os réus transpassando pela grade do estabelecimento tentando a evasão, depois de retirarem a fiação do imóvel.

O concurso de pessoas pressupõe que a vontade dos agentes seja voltada para o mesmo fim, pouco importando que haja prévio acordo de vontades. No caso dos autos, ambos os réus ingressaram no supermercado e se uniram para a retirada da fiação, deixando o local juntos, a indicar que estavam unidos com o objetivo de subtrair os bens e, portanto, o concurso de pessoas deve ser reconhecido.

4) Da tentativa

A jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior de Justiça adotou a teoria da apreensão ou amotio, no sentido de que o furto de consuma com a posse do bem desde que se tenha cessado a clandestinidade.

Nesses termos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apreensão (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

Como os réus retiraram a fiação, estavam saindo do imóvel, quando foram abordados, não conseguiram fazer cessar a clandestinidade, deve ser reconhecida a figura tentada.

5) Do repouso noturno

Inicialmente, cumpre verificar a possibilidade de aplicação da causa de aumento do furto noturno à sua figura qualificada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça havia alterado o entendimento, até então pacífico, para autorizar a existência do furto qualificado noturno.

Recentemente, contudo, esse entendimento foi afastado, em sede de recurso repetitivo e, portanto, de aplicação cogente, para entende que aos furtos qualificados não é possível o reconhecimento da causa de aumento do furto noturno.

É este o teor do Tema 1087 do Superior Tribunal de Justiça: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática de crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua figura qualificada (§ 4º)"

Nesse sentido, a nova jurisprudência:

HABEAS CORPUS Nº 748471 - SC (2022/0178253-0) DECISÃO VALDECI DOS SANTOS alega sofrer constrangimento ilegal no seu direito de locomoção em decorrência de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina na Apelação n. 5020649-51.2021.8.24.0023. Neste writ, a defesa requer o afastamento da majorante do repouso noturno ao furto qualificado, ao argumento de a exasperação é desproporcional e está em contrariedade com a atual jurisprudência desta Corte Superior. Decido. O habeas corpus comporta pronta solução, pois a pretensão defensiva está respaldada em tese fixada no tema repetitivo n. 1.087. Deveras, em recente acórdão prolatado em 25/5/2022 (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, pendente de publicação), que constituiu overruling do entendimento até então adotado, a 3ª Seção do STJ fixou a tese de que "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)" (destaquei). No caso em exame, o paciente foi condenado a 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal. Assim, em atenção ao sistema de precedentes qualificados e à nova orientação desta Corte Superior, a majorante do repouso noturno deve ser excluída da dosimetria. Passo, portanto, ao redimensionamento da sanção. A pena-base do agente foi fixada em 2 anos de reclusão, além de 10 dias-multa. Na segunda etapa, reconhecida a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda ficou em 2 anos e 2 meses de reclusão mais 11 dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, deve ser decotada a causa de aumento do art. 155, § 1º, do CP. Assim, ausentes outras moduladoras, a pena definitiva é de 2 anos e 2 meses de reclusão mais 11 dias-multa. À vista do exposto, concedo a ordem in limine, a fim de redimensionar a pena do paciente para 2 anos e 2 meses de reclusão mais 11 dias-multa. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 13 de junho de 2022. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Relator (STJ - HC: 748471 SC 2022/0178253-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 17/06/2022 - grifei)

6) Do princípio da insignificância

Alegou a Defesa a necessidade de reconhecimento da atipicidade da conduta, em razão da necessidade de aplicação do princípio da insignificância.

Formulado por Claus Roxin, em seu Política Criminal y sistema del Derecho Penal, esse princípio se refere àquelas condutas que lesionam minimamente ou causam risco de lesão mínima a um bem jurídico penalmente protegido, de forma que não deveria haver a imposição de pena criminal.

E para dar maior segurança jurídica na aplicação desse princípio, o Supremo Tribunal Federal delimitou sua aplicação:

"O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA

E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: 'DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR'. - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social". PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. (STF - 2ª Turma - Rel. Min. Celso de Mello - HC 84.412-SP - v.u. 19.10.2004 - D.J. 19.11.2004).

Assim, sustenta o Tribunal Superior acima que para que se aplique validamente o princípio da insignificância sem gerar insegurança jurídica, necessário que estejam presentes os seguintes requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente; a nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Com isso, não fica o princípio da insignificância restrito ao aspecto quantitativo da lesão causada pelo ato ilícito, mas se amplia para tocar os aspectos sociais e econômicos da própria conduta do agente, além de exigir que se observem as condições pessoais do sujeito ativo do delito.

Pessoa primária, sem antecedentes de monta, de pouca idade, que pratique delito sem violência nem grave ameaça contra a pessoa e que tenha diminutos resultados materiais e socioeconômicos é merecedora da aplicação do princípio da insignificância, afastando-se a tipicidade de seu comportamento.

Se, do contrário, trata-se de pessoa que costumeiramente ataca bens jurídicos alheios, violando o direito de propriedade, a incolumidade pública, entre outros, essa não merece tratamento benéfico, não se podendo invocar a aplicação do princípio da insignificância, ainda que seja de diminutas consequências seu agir. E assim vem julgando a Corte suprema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-APLICAÇÃO. CONTUMÁCIA